



TRIBUNALE DI SCIACCA

Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Nei procedimenti riuniti n. 12/14 e nn. 84, 85, 86 e 87/2015 R.G.

All'udienza del 15 febbraio 2016 sono comparsi per la discussione orale della causa innanzi al G.I. Dottor Filippo Lo Presti: per *Controparte_1* l'Avvocato Omar Gianpaolo Mohamed Ahimed; per il *CP_2* *Parte_1* l'Avvocato Pellegrina Falco. L'opponente discute la causa riportandosi alle note scritte che deposita.

L'Avvocato Falco si riporta ai propri scritti che controparte contesta anche con riferimento al contenuto della produzione documentale; segnala inoltre *CP_1* [...] che il canone, non dovuto, sarebbe comunque legato al numero dei contratti e non delle singole utenze riconducibile a ciascun contratto.

Questa impostazione è constatata dall'Avvocato Falco.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 15/02/2016, riaperto il verbale del procedimento n. 12 del RG dell'anno 2014, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.

Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI SCIACCA

Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 12 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014

TRA

Controparte_1 *P.IVA_1* , rappresentato e difeso dall'Avvocato MOHAMED AHMED OMAR GIANPAOLO in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione

opponente

CONTRO

Controparte_3 (*P.IVA_2*), in persona del Sindaco pro tempore, e rappresentato e difeso dall' Avv. FALCO PELLEGRINA in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e di Delibera di G.M. in atti.

CONVENUTA

Oggetto: opposizione avverso ordinanze di ingiunzione.

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando:

rigetta le opposizioni riunite contro le ordinanze di ingiunzione nn. n. **97** del 6.12.2013; **121, 59, 26 e 48** del 22.12.2014.

Condanna *Controparte_1* a pagare le spese di lite in favore del *Controparte_3* in persona del Sindaco pro tempore, liquidandole in euro 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % come per legge.

~~~~~

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le opposizione riunite (cfr. ordinanza dell'11 maggio 2015 e ordinanza del 25 gennaio 2016) la *Parte\_2* che gestisce il servizio idrico integrato nell'interesse dei Comuni agrigentini costituiti in *Controparte\_4* in virtù di apposita Convenzione/concessione del 27 novembre 2007, ha impugnato le ordinanze di ingiunzione con le quali il *Controparte\_3* le ha intimato il pagamento del *Org\_1* (Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche) per gli anni 2009 (ord. n. 97 del 6.12.2013), 2010 , 2011, 2012 e 2013 (ordinanze ingiunzione nn. 121, 59, 26 e 48 tutte del 22.12.2014); i provvedimenti opposti sono tutti prodotti in atti e regolarmente notificati. L'opponente ha chiesto l'annullamento delle ingiunzioni sopra indicate per i seguenti motivi:

**1)** Difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente –L. n. 212 del 2000. Non si comprenderebbe, dal tenore delle

ordinanze ingiunzione sulla scorta di quali elementi sia stato quantificato il canone e non si comprenderebbe neppure sulla base di quali ragioni in fatto ed in diritto, siano state azionate le richieste di pagamento. Non basterebbe in tale senso l'indicazione del mero presupposto della occupazione con cavi ed impianti ed il riferimento all'erogazione di pubblici servizi.

**2) Mancanza dei presupposti per l'applicazione del canone:**

**a)** perché **CP\_1** non trae “*alcun beneficio economico*” dall'utilizzo del suolo pubblico, come emerge del resto dall'art. 154 del D.lgs. - n. 156 de 2006 in base al quale la determinazione della tariffa pagata dall'utente per l'erogazione del servizio idrico assolve soltanto alla copertura dei costi di gestione, senza alcun utile per la società erogatrice. In ogni caso, ha aggiunto **CP\_1** è determinante il fatto che in base all'art. 33 della Convenzione di affidamento del servizio, al termine del rapporto, gli impianti e la rete utilizzata dalla società deve essere restituita gratuitamente agli enti locali, e questa circostanza corrisponde ad un caso di specifica esenzione dal pagamento del **Org\_1**

**b)** perché anche la Convenzione, all'art. 9 comma 5, prevede la concessione gratuita del suolo e del sottosuolo per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere strumentali all'erogazione del servizio;

**c)** perché l'occupazione imputabile a **CP\_1** essendo relativa ad un “servizio” pubblico e non già ad un “esercizio” pubblico non rientra nell'ambito normativo dell'art. 24 del regolamento comunale sul Cosap in materia di determinazione della tariffa; anzi, in base all'art. 29 di quel regolamento, il “servizio” idrico integrato deve ritenersi rientrante nel catalogo delle ipotesi di esenzione espressamente previste da quell'articolo.

**3) Mancata indicazione delle modalità di determinazione del **Org\_1** risultando comunque errata l'applicazione del criterio legale indicato dall'art. 63 lett. f) del D.lgs. n. 446 del 1997 –che fa riferimento al numero delle utenze- essendo stato indicato in modo inesatto il numero delle utenze riconducibili alla demografia del Comune di **CP\_3** .**

In particolare, siccome il numero delle utenze saccensi è di 11.000,00 e non già di 19.063, con le ordinanze ingiunzione impugnate sono state richieste –a dire dell'opponente- somma in eccesso, posto che il Cosap esatto per ciascun anno considerato ammonterebbe soltanto ad euro 7.150,00.

A valle di ciò, **CP\_1** ha contestato anche l'applicazione della sanzione irrogata con le ordinanze ingiunzione facendo appello a quanto stabilisce l'art. 3 della l. n. 689 del

1981: il mancato pagamento del Cosap è dipeso –secondo l’opponente- da *Parte\_3* dalla Convenzione stipulata con l’*CP\_5* *Parte\_4* e perciò non le è imputabile. Sulla scorta di tutti questi motivi, l’opponente ha chiesto l’annullamento delle ordinanze impugnate ed in subordine che si accerti l’errata indicazione del *quantum* richiesto e si annulli l’applicazione della sanzione irrogata. In tutti e cinque i procedimenti riuniti si è ritualmente costituito il *Controparte\_3* in persona del Sindaco *pro tempore* chiedendo il rigetto delle opposizioni.

Secondo il Comune opposto sarebbe priva di fondamento la contestazione relativa all’asserito difetto di motivazione delle ordinanze impugnate, atteso che in tutte vi è chiaro riferimento al presupposto di applicazione del Canone consistente nella occupazione del sottosuolo per l’erogazione del servizio idrico; analogamente, sarebbe priva di consistenza l’obiezione relativa alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione della richiesta ingiunta, posto che il parametro di riferimento è stabilito dalla legge in base al numero di utenze.

Non sarebbe condivisibile neppure l’impostazione dell’opponente in punto di carenza di presupposto fattuale per l’applicazione del *Org\_1*, tenuto conto che è pacifico che *CP\_1* [...] occupa le reti idriche comunali e non esistendo clausole di esonero dal pagamento del *Org\_1* in favore della erogatrice del servizio.

Anche l’art.30 di quella Convenzione del resto prevede che *CP\_1* debba pagare “*tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune*”.

Ha chiesto perciò il rigetto delle opposizioni riunite.

Così introdotti i termini della questione, occorre preliminarmente rammentare che è oramai pacifica la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie che hanno ad oggetto il diritto al pagamento del Cosap: ciò, innanzitutto, alla luce di quanto dispone il nuovo testo dell’art. 2, D.lgs. n. 546 del 1992; e tenendo conto peraltro ed in ogni caso del fatto che nell’ambito della rapporto di concessione (di natura privatistica) dell’area pubblica tra il privato e l’Ente territoriale, il *Org\_1* assolve alla funzione di corrispettivo e non già di entrata tributaria.

Tanto premesso, è adesso il caso di rammentare che con il D.lgs. n. 446 del 1997 –art. 63- l’applicazione della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è divenuta facoltativa, essendo stato attribuito alle Province ed ai Comuni il potere di prevedere con apposito regolamento che l’occupazione, permanente o temporanea, di strade aree e relativi

spazi anche sottostanti appartenenti al proprio demanio sia assoggettata, “in sostituzione” di quel tributo, al pagamento di un “canone” –COSAP- a carico del titolare della concessione e “determinato” nel medesimo atto di concessione.

In tal senso, i Comuni “possono adottare” appositi regolamenti per escludere la Tosap ed introdurre in sua sostituzione il Cosap. Ed è evidente che la natura dei due pesi è diversa perché soltanto la Tosap è una tassa e genera gettito fiscale con ciò che ne consegue in punto di sistema di riscossione e di imputazione nel bilancio dell’Ente. La *Org\_1* invece, ha natura di corrispettivo della concessione, reale o presunta, dello spazio pubblico.

In tale quadro normativo emerge che a fronte dell’occupazione dell’area o del suolo pubblico, l’Ente Locale ha due possibilità: o riscuotere la Tosap, oppure prevedere in sua “sostituzione” l’applicazione del Cosap determinandolo in modo preciso con l’atto di concessione, vale a dire con il titolo che disciplina il rapporto di godimento dell’area pubblica da parte del privato; rapporto che, a quel punto, assume i connotati della relazione di diritto privato in base al titolo di concessione.

In questo contesto l’unica discrezionalità ammessa in favore dell’Ente Locale afferisce alla scelta circa la sostituzione della Tosap con il Cosap ed alla “determinazione” del Canone nonché di stabilire delle “speciali agevolazioni” soltanto per *“occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politico istituzionale”*.

Ciò posto è la legge e non l’Ente locale ad identificare il presupposto per il pagamento del Canone demandando al titolo di concessione soltanto la determinazione del suo *quantum*.

Ma proprio rispetto a tale ultimo aspetto, si deve considerare che la lettera *f)* dell’art. 63, D.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che, proprio in ordine alla erogazione di “pubblici servizi”, la determinazione del canone è forfettizzata in base al numero delle utenze ed alla demografia dell’area comunale; essendo con ciò chiaro che, rispetto a quella particolare materia la mancata previsione della dettagliata determinazione nel titolo di concessione non è necessaria essendo invero prevista dalla legge.

Fatte queste premesse, nel caso in esame *CP\_1* contesta innanzitutto la legittimità delle ordinanze ingiunzione perché viziate da difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dello Statuto del Contribuente.

Ebbene, senza doversi soffermare, per le ragioni esposte, sulla pertinenza del riferimento fatto alla L. n. 212 del 2000 (Stat. Contr.), ritiene chi giudica che il motivo di opposizione sia infondato.

Tutte le ordinanze ingiunzione impugnate fanno chiarissimo riferimento alle ragioni della richiesta di pagamento, e cioè: all'occupazione permanente per erogazione di pubblico servizio sull'Area Unica Comunale; al periodo di riferimento; al numero delle utenze. Tutti elementi idonei e sufficienti per rendere **Pt\_5** **CP\_1** che la pretesa ingiunta faceva riferimento all'erogazione del servizio idrico da lei somministrato per gli utenti dell'area comunale di **CP\_3**.

Ed è appena il caso di rilevare che l'assolvimento dell'obbligo di motivazione va valutato in relazione alla funzione che gli è attribuita, che è quella di consentire al destinatario dell'atto di comprendere le ragioni del provvedimento trasmessogli; di modo che la contestazione relativa all'asserito difetto di motivazione non è meritevole allorquando, come nella specie, risulti finalizzata soltanto a stigmatizzare un'inadeguatezza meramente formale o stilistica dell'atto. E si consideri che con la propria opposizione **CP\_1** ha compiutamente segnalato i termini della pretesa comunale, sviluppando tutte le proprie ragioni di opposizione.

Il motivo di impugnazione delle ordinanze ingiunzione è perciò infondato.

Per quanto riguarda la questione principale della vicenda, relativa alla sussistenza o meno dei presupposti impositivi, si deve innanzitutto ribadire che l'unico presupposto di fatto previsto dalla legge per l'esigibilità del **Org\_1** è costituito dall'uso particolare di beni aree e spazi del suolo o del sottosuolo pubblici.

Proprio con riferimento particolare alle aziende erogatrici di pubblici servizi, l'art. 63, comma secondo lettera f) del D.lgs. n. 446 del 1997 prevede che il soggetto passivo del **Org\_1** sia individuato nell'azienda che realizza l'occupazione con cavi, condutture, impianti. La norma, usando la formula "reti realizzate da aziende" non chiarisce se il soggetto obbligato sia l'erogatore del servizio che realizzi direttamente i cavi, le condutture e gli impianti oppure anche l'azienda che li utilizzi senza averli realizzati e senza esserne proprietaria. Potendosi, invero, in base al tenore della norma immaginare che il soggetto obbligato sia soltanto chi utilizzi il suolo per "realizzare" le infrastrutture e non invece chi si limita ad impiegarle in quanto autorizzato dal primo –come avviene nel caso di specie, laddove la rete è stata realizzata dal **CP\_2** mentre **CP\_1** si sta limitando ad utilizzarla, senza averla realizzata e non essendone proprietario.

Su punto è utile rilevare che il **Organizzazione\_2** con una prima Circolare interpretativa del 2000 aveva già posto l'accento sul solo requisito della titolarità della concessione affermando che "*i soggetti tenuti al pagamento del canone devono essere esclusivamente individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in*

questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione. Non possono pertanto considerarsi assoggettate al pagamento del C.O.S.A.P. le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione è realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si realizza nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima l'applicazione" (Ministero delle finanze Circ. 28/02/2000, n. 32/E). Questa circolare, nel segnalare la centralità dell'utilizzo non aveva però preso espressa posizione in merito all'ipotesi di scissione tra il titolare della concessione ed il proprietario della rete, lasciando nel dubbio l'interprete che si confronti con l'espressione indicata nel secondo periodo laddove richiama le reti realizzate "da altre società".

E tuttavia, con una successiva Circolare del 2009, il **Org\_2** ha precisato che siccome *"l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni [...] Una lettura dinamica delle norme in questione, che si rende necessaria al fine di non vederne vanificata la portata, induce a ritenere che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti a titolo di TOSAP o di **Org\_1** calcolati sulla base del numero delle proprie utenze....poiché è innegabile che non solo le società che materialmente effettuano l'occupazione del suolo pubblico ma anche quei soggetti che contestualmente utilizzano dette strutture svolgono un servizio di pubblica utilità. Questi ultimi, inoltre, effettuano anch'essi un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso cioè l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti"*. (Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 20 gennaio 2009, n. 1/DF).

L'impostazione interpretativa del **Org\_2** laddove denota il corretto perimetro del presupposto del **Org\_1** nella utilizzazione delle infrastrutture da chiunque realizzate nel sottosuolo pubblico, ed indipendentemente da chi ne sia proprietario, è assolutamente condivisibile; ed invero, è proprio l'utilizzo delle infrastrutture che, implicando quello del suolo o del sottosuolo pubblico, integra senza dubbio il godimento dell'area pubblica rendendo esigibile, in punto di presupposto fattuale, il pagamento del Canone da parte dell'**Org\_1** Locale.

Sgombrato il campo da ogni preliminare questione interpretativa circa la fattispecie presupposta dalla disciplina sul **Org\_1** va ulteriormente chiarito che con la Convenzione/Concessione del 27 novembre 2007, gli Enti Locali riuniti in **CP\_4** non hanno affatto esentato **CP\_1** dal pagamento del **Org\_1**. Ed invero l'art. 5 della convenzione prevede l'utilizzo gratuito del sottosuolo soltanto per la "installazione" delle opere e degli impianti necessari per effettuare il servizio e non anche per l'utilizzo della rete idrica già realizzata dagli Enti –tra cui il **Controparte\_3**

E d'altra parte l'art. 30 della Convenzione suddetta è chiarissimo nello stabilire che *"Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune..."*

Ed allora, atteso che: **1)** con Regolamento comunale n. 44 del 13 febbraio 2003, il Comune di **CP\_3** aveva già stabilito di sostituire la Tosap con la **Org\_1** **2)** che l'art. 29, lettera k) di quel Regolamento non prevede una esenzione per il gestore/erogatore del servizio idrico ma soltanto per gli utenti dei sistemi fognari, ed idrici che devono "innestarsi" o "allacciarsi" alla rete idrica per l'uso dell'acqua potabile o per l'irrigazione fondi; **3)** che neppure è applicabile l'esenzione di cui alla lettera l), tenuto conto che la rete idrica utilizzata da **CP\_1** è già del **CP\_2** e che l'esenzione riguarda, evidentemente, soltanto il caso di devoluzione gratuita al **CP\_2** degli impianti installati direttamente dal gestore e non certo di quelli che l'ente possiede.

Non resta che concludere che nel caso di specie, sin dalla data di stipula della Convenzione del 2007 sussisteva il diritto del **CP\_2** di pretendere il pagamento del **Org\_1** da parte di **CP\_1** per l'occupazione della rete idrica comunale.

A tal proposito occorre in ogni caso considerare che, fermo restando quanto sopra detto in ordine al rilievo offerto dall'art. 30 di quella Convenzione –che fa riferimento ai canoni comunque dovuti ai Comuni-, l'applicazione del Cosap non può essere messa in dubbio sol perché la Convenzione non fa espresso rinvio ai Regolamenti comunali in materia. Ed invero, è appena il caso di rilevare come ai sensi dell'art. 1339 c.c., letto unitamente all'art. 1374 c.c., la concessione tra **CP\_1** ed il **Controparte\_3** –quale parte del **Controparte\_6** deve intendersi comunque integrata automaticamente sia da quel Regolamento comunale (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 19531 del 2004) sia, prima ancora dall'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 che, come detto, per un verso non consente una generica esenzione del Cosap e per altro verso stabilisce direttamente la tariffa per le occupazioni permanenti relative alla erogazione di pubblici servizi.



Nel caso di specie l'applicazione del Cosap e la sua determinazione non è influenzata nemmeno dal fatto che in base all'art. 19 della Convenzione, la *CP\_1* sia tenuta a pagare annualmente agli Enti Locali un autonomo "canone di concessione". Ed invero, tacendo il fatto che quella norma smentisce l'opponente laddove sostiene la natura gratuita della concessione delle reti, si deve osservare che, in base a quanto disposizione il terzo comma dell'art. 64, D.lgs. n. 446 del 1997, l'importo di quel canone non incide sull'obbligo di pagamento del *Org\_1* in quanto connesso a prestazioni di servizi.

Anche il riferimento al numero di utenze indicato dal *Controparte\_3* è corretto, non essendo condivisibile la tesi di *CP\_1* secondo cui la tariffa dovrebbe essere calcolata sul numero dei contratti (indicati dallo stesso *CP\_7* all. n. 7- in poco di undimila). Ed invero, l'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997, alla lettera f) fa chiarissimo riferimento al numero delle utenze; ossia al numero degli allacci da parte di soggetti che usufruiscono del servizio; e ciò vale anche nel caso in cui ad un singolo contratto corrispondano più utenze autonome come nel caso dei condomini.

Per tutte le ragioni indicate, le opposizioni riunite vanno rigettate anche sotto il profilo dell'applicazione delle sanzioni: *CP\_1* proprio in virtù di quanto stabilisce il su richiamato art. 30 della Convenzione del 2007, era perfettamente al corrente del suo obbligo di pagare il *Org\_1* al *Controparte\_3*

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Così deciso in Sciacca, il 15/02/2016

Il Giudice  
Filippo Lo Presti

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.